

1500859-24.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500859-24.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500859-24.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210280/2021 - DEL.POL.JARINU, 19422574 - DEL.POL.JARINU, 747/21/415 - DEL.POL.JARINU, 2210280 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CINTIA OLIVEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de CINTIA OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos deste processo crime, dando-a como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no 04 de agosto de 2021, por volta das 23h40, na Rua Ernesto da Silva Picolomini, 744, bairro Vila Nova Trieste, nesta cidade e comarca de Jarinu, a acusada trazia consigo, guardava e transportava, para fins de tráfico, 07 (sete) microtubos de "crack", com massa líquida de 0,48g, e 91 (noventa e um) eppendorfs de "cocaína em pó", com massa líquida de 38,38 g, substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 175,00.

A denúncia foi recebida em 27/08/2021 (fl. 85).

Citada, a ré ofertou defesa prévia (fls. 110/112).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 117/118), prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas, sendo a denunciada, ao final, interrogada.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Ministério Público e Defesa se manifestaram memoriais escritos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 02/04), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), do laudo preliminar de constatação da natureza tóxica (fls. 24/26), do laudo pericial químico de entorpecente (fls. 72/74), que atestou que a substância encontrada se tratava de cocaína, de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída à acusada.

Inquirida, a testemunha José Ailton Ferreira da Silva, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento na data dos fatos; que se depararam com a autora, a qual demonstrou certo nervosismo; que, realizada a abordagem, constataram a presença de bolsa com certa quantidade de entorpecentes; que, na bolsa de mais ou menos cinco centímetros de diâmetro, havia 91 porções de cocaína e 7 se de crack, além de 175 reais; que confessou informalmente a prática do delito; que vendia drogas em nome de terceira pessoa apelidada de "Batata"; que não conhecia a ré antes dos fatos.

A testemunha Cleiton Roberto de Souza, também integrante da GM, relatou que estavam em patrulhamento; que avistaram a acusada, que demonstrou nervosismo; que carregava nas mãos uma bolsa, contendo entorpecentes; que confidenciou aos guardas que estava em Jarinu há cinco dias e que trabalhava para o "Batata"; que ela sabia que carregava entorpecentes; que alegava que eram dela; que outra guarnição prendeu, dias depois, o suposto "Batata" por tráfico; que a ré carregava crack e cocaína.

Interrogada, a denunciada CINTIA OLIVEIRA DA SILVA disse que a acusação não é verdadeira; que é usuária e foi à praça na ocasião apenas para comprar maconha; que estava esperando o vendedor chegar quando a viatura passou; que os guardas pediram para pegar a bolsa, no que entregou a eles; que não falou que era sua.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra da acusada encontra-se em dissonância do conjunto probatório, em especial do relato das testemunhas que efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

De proêmio, destaco que a ré foi presa em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a "certeza visual do crime" (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

No mais, não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão

Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011).

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Acrescento que a versão trazida pela acusada restou ilhada dos elementos dos autos. Observo, também, que o fato de a acusada ser usuária não impede que ela estivesse no local também efetuando a venda de entorpecentes, como no caso, eis que não são raros os usuários que se valem da mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício:

"(...) a alegação de usuário ou de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJESP 101/498).

"No mais, como é mais do que sabido, a eventual condição de usuário alegada pelo Réu em seus interrogatórios - não obsta o reconhecimento da atividade da traficância pelo mesmo agente, como bem já decidiu esta Câmara (Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013): "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (Apelação Criminal nº 0000731-32.2020.8.26.0022, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado em 07.03.2022).

In casu, os testemunhos dos guardas prestados em juízo, de forma coesa e harmônica, consubstanciam mesmo prova suficiente para um édito condenatório.

Outrossim, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as drogas apreendidas não seriam de sua propriedade ou que não se destinavam ao comércio espúrio.

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, conquanto inexistam antecedentes (fl. 30), a lesividade das substâncias encontradas, especialmente o crack, impõe elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que a denunciada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem, deixo de valorar a natureza e a quantidade de

entorpecentes apreendidos, já que o Pretório Excelso passou a considerar vedada a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

À míngua de elementos acerca da capacidade financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigente, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR a ré CINTIA OLIVEIRA DA SILVA, já qualificada nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento e o quantum de pena aplicada, bem como a sua substituição, de todo incompatíveis com a prisão preventiva, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Condeno a acusada nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada.

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Arbitre os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Jarinu, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA